

1501536-86.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/01/2022

... Ademais, o réu foi visto em atitude típica de tráfico ilícito de drogas, ou seja, quando entregava algo a terceira pessoa não identificada e receberia dinheiro em troca.

Pertinente salientar que não há nada que invalide os depoimentos dos policiais, devendo ser valorados como as demais provas constantes no processo.

Neste sentido:

APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 05/07, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19)3433-4177, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501536-86.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2272563/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 20674669 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO,

2753/21/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2272563 - 02º D.P. PIRACICABA,

2753/21/922 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS FERNANDO DA SILVA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 24 dias do mês de janeiro de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr.Paulo Kishi e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr(a).Daniela Bataíha Trettel. Apresentados o(a)(s) acusado(a)(s) LUCAS FERNANDO DA SILVA e as testemunhas arroladas em comum pelas partes Glaucia Aceipção Milton Leal e Letícia Delolio Battagin.

Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com seu(sua)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao(a)(s)

acusado(a)(s) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) (Glaucia e Letícia) pelo sistema virtual e, em seguida, interrogado(a)(s) o(a)(s) réu(ré)(s).

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

“Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM. Juíza,

LUCAS FERNANDO DA SILVA foi denunciado e está sendo processado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 05 de outubro de 2021, por volta de 20h17m, no “Bar da Pantera”, localizado à rua Pedro Ferraz Pacheco, bairro Piracicamirim, nesta cidade e comarca, mantinha em depósito e/ou guardava 23 porções de cocaína, destinadas à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, substância entorpecente que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os fatos imputados na exordial acusatória foram comprovados ao longo da instrução criminal, pelo que a ação é procedente.

A autoria e materialidade foram devidamente comprovadas.

Segundo se apurou, guardas civis passavam pelo local, quando avistaram o denunciado em atitude típica de tráfico ilícito de drogas, ou seja, “um indivíduo entregando algo para outro que lhe entregou um objeto que parecia ser uma nota de real”. Ao perceber a aproximação da viatura, a pessoa que entregava o dinheiro puxou a nota da mão do denunciado e correu. Em seguida, o denunciado passou a disfarçar ao lado de uma mesa do estabelecimento.

Feita abordagem de praxe, em poder do denunciado foi localizada a quantia de R\$ 10,00 e em uma fresta na mesa ocupada por ele foram encontradas 23 porções de cocaína.

Instado, informalmente, o denunciado negou a propriedade da droga. Perante a autoridade policial, ele permaneceu em silêncio.

Diante das circunstâncias apuradas, local, apreensão de porções individualizadas e apreensão de dinheiro, infere-se que a droga apreendida destinava-se à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas.

Com efeito, a testemunha Glaucia Aceipção Milton Leal disse “é guarda civil municipal e na data de hoje estava em deslocamento com a viatura da patrulha Maria da Penha pela Avenida Rio das Pedras quando nas proximidades do Bar do Pantera visualizou um indivíduo entregando algo para outro que lhe entregou um objeto que parecia ser uma nota de Real. Ao perceber a aproximação da viatura o indivíduo que entregou o dinheiro, puxou a nota da mão do outro e correu e o indivíduo que entregava o objeto ficou no local, disfarçando, dando a entender que estava no Bar. Foi realizada a abordagem àquele indivíduo, o qual identificou-se como sendo Lucas Fernando da Silva e em sua posse foi encontrada quantia de R\$10,00. Lucas estava parado encostado em uma mesa do bar e em revista àquela mesa foi encontrado, escondido em uma fresta da mesma, 23 pedras de crack. Lucas negou a propriedade de entorpecente. Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante a Lucas Fernando da Silva sendo o mesmo apresentado nesta unidade policial” (fls. 03).

Em juízo ratificou o depoimento prestado na fase policial e disse que presenciou o momento em que o réu estava comercializando drogas no local. Ele foi abordado , foi dada voz de parada e ele ignorou a ordem. Próximo a ele apreenderam a droga descrita na inicial e com ele foi apreendida a quantia de R\$ 10,00. Não conhecia o réu. O local é conhecido ponto de venda de drogas. Só havia o réu próximo às mesas. Só ele estava lá e foi visto mexendo.

No mesmo sentido, a guarda civil Leticia Delolio asseverou que “guarda civil e desempenha suas funções na Patrulha Maria da Penha. Hoje estava em deslocamento com a viatura 98 da referida patrulha, e quando passava pela Avenida Rio das Pedras,

nas proximidades do Bar do Pantera, visualizou um indivíduo entregando algo para outro que lhe entregou alguma coisa que pareceu ser uma nota de Real. Ao perceber a aproximação da viatura o indivíduo que entregou o dinheiro, puxou a nota da mão do outro e correu e o indivíduo que entregava o objeto ficou no local. Para disfarçar ele dirigiu-se até a porta do bar e ali permaneceu, encostado em uma mesa do lado de fora. Foi realizada a abordagem àquele indivíduo e em sua posse foi encontrada a quantia de R\$ 10,00. Em revista a mesa que ele estava encostado, foi encontrado, escondido em uma fresta da mesma, 23 pedras de crack. Lucas negou a propriedade do entorpecente" (fls. 04).

Em juízo ratificou o depoimento prestado na fase policial edisse que viu o momento em que o réu estava comercializando droga, inclusive vieram ele entregando algo e recebendo a nota de dinheiro. Ele foi abordado, foi dada voz de parada e ele ignorou a ordem. No local em que ele foi visto, no local apreenderam entre as mesas uma sacola com várias porções de droga que aparentava ser crack. O terceiro que foi visto transacionando com o réu logrou evasão correndo, inclusive viu-o puxando o dinheiro da mão do réu. Não conhecia o réu antes dos fatos. O local é conhecido como ponto de venda de drogas.

Perante a autoridade policial, o réu permaneceu em silêncio (fls. 05/06).

Interrogado em juízo, o réu disse que já foi condenado por roubo e furto. Alegou que havia ganhado dez reais e foi ao bar para comprar uma pedra de crack para seu consumo. Não chegou a comprar a droga. Foi algemado pelas guardas civis. A pessoa que correu também estava esperando para comprar droga. Não indicou aos guardas a pessoa que estava vendendo porque iria arrumar "encrenca".

Diante do todo apurado há provas suficientes que demonstram que o réu foi autor do delito em questão.

A narrativa das guardas civis foi firme e uníssona em confirmar que passavam pelo local, quando avistaram réu em atitude típica de tráfico. Ao perceber a aproximação ele tentou disfarçar e retornou à mesa que ocupava em um bar. Feita abordagem de praxe, em poder do réu foi localizada a quantia de R\$ 10,00. Outrossim, escondida em uma fresta na mesa ocupada por ele, foram localizadas 23 porções de crack.

Assim, as circunstâncias do delito, local, quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente evidenciam que a droga destinava-se à mercancia ilícita. Ademais, o réu foi visto em atitude típica de tráfico ilícito de drogas, ou seja, quando entregava algo a terceira pessoa não identificada e receberia dinheiro em troca. Pertinente salientar que não há nada que invalide os depoimentos dos policiais, devendo ser valorados como as demais provas constantes no processo.

Neste sentido:

APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06.

Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Valor do depoimento testemunhal de servidores policiais que, ratificados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Inexistência de contradições ou elementos de convicção que possam retirar-lhe a credibilidade. Dosimetria da pena mantida. Regime inicial fechado adequadamente imposto. Análise da detração que compete ao Juízo das Execuções Criminais. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação nº 3005429- 53.2013.8.26.0320, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Camargo Aranha Filho, j .05/05/2016) – Grifo nosso Salienta-se que as guardas civis não conheciam o réu e não tinham motivos para incriminá-lo injustamente.

Ademais, a negativa do réu está isolada e não merece nenhuma credibilidade.

Destarte, diante do conjunto probatório, imperiosa a condenação do réu pelo delito imputado na inicial.

Passo a analisar a dosimetria da pena.

Na primeira-fase a pena deverá ser fixada acima do mínimo legal, pois o réu ostenta maus antecedentes.

O réu é reincidente, razão pela qual a pena deverá ser agravada. Ausentes atenuantes, causas de aumento e de diminuição.

Incabível, a benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, pois o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes, o que obsta a concessão da benesse.

O regime inicial deve ser o fechado diante da gravidade em concreta do delito.

Ademais, ele ostenta maus antecedentes e é reincidente, o que demonstra que condenações anteriores não foram capazes de alcançar a finalidade da pena. Incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois ausentes os requisitos.

Destarte, requer seja julgada procedente a ação penal e o réu condenado nos exatos termos da inicial.

Presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente garantia da ordem pública, deverá ser indeferido o apelo em liberdade.

Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s), manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, Lucas Fernando da Silva foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Segundo a denúncia (fls. 97-99), no dia 05 de outubro de 2021, por volta de 20h17, no "Bar da Pantera", localizado à rua Pedro Ferraz Pacheco, bairro Piracicamirim, nesta cidade e comarca de Piracicaba/SP, Lucas mantinha em depósito e/ou guardava 23 porções de cocaína, destinadas à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas.

Ainda de acordo com a inicial, guardas civis passavam pelo local, quando avistaram o réu em atitude típica de tráfico ilícito de drogas, ou seja, "um indivíduo entregando algo para outro que lhe entregou um objeto que parecia ser uma nota de real". Ao perceber a aproximação da viatura, a pessoa que entregava o dinheiro puxou a nota da mão do réu e correu. Em seguida, o réu passou a disfarçar ao lado de uma mesa do estabelecimento. Feita abordagem, em poder do réu foi localizada a quantia de R\$ 10,00 e em uma fresta na mesa ocupada por ele foram encontradas 23 porções de cocaína. Instado, informalmente, o réu negou a propriedade da droga. Interrogado em solo policial, o réu exerceu o seu direito constitucional ao silêncio (fls. 5-6).

Glaucia Aceipção Milton Leal, guarda civil, narrou que: "é guarda civil municipal e na data de hoje estava em deslocamento com a viatura da patrulha Maria da Penha pela avenida Rio das Pedras quando nas proximidades do Bar do Pantera visualizou um indivíduo entregando algo para outro que lhe entregou um objeto que parecia ser uma nota de Real. Ao perceber a aproximação da viatura o indivíduo que entregou o dinheiro, puxou a nota da mão do outro e correu e o indivíduo que entregava o objeto ficou no local, disfarçando, dando a entender que estava no Bar. Foi realizada a abordagem àquele indivíduo, o qual identificou-se como sendo Lucas Fernando da Silva e em sua posse foi encontrada quantia de R\$10,00. Lucas estava parado encostado em uma mesa do bar e em revista àquela mesa foi encontrado, escondido em uma fresta da mesma, 23 pedras de crack. Lucas negou a propriedade de entorpecente. Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante a Lucas Fernando da Silva sendo o mesmo apresentado nesta unidade policial. Não conhecia o autuado" (fls. 3).

No mesmo sentido a versão apresentada pela guarda municipal Leticia Delólio Battagin (fls. 4).

Às fls. 44-46, juntada certidão de objeto e pé que indica a reincidência do requerido (autos n.º 0014191-36.2015.8.26.0451 - furto - trânsito em julgado para Defesa em 9-5-2017; autos n.º 0016435-98.2016.8.26.0451 - roubo - pena cumprida em 16-9-2019).

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

A materialidade do delito se comprova pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10-11, fotografia de fls. 12, laudo de constatação de fls. 15-17 e laudo de exame definitivo de fls. 131-133.

Com relação à autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

a) Ouvida, inicialmente, Glaucia Aceipção Milton Leal, guarda civil. Explicou que faz parte da ronda Maria da Penha. Tinham feito visita a uma pessoa que está no programa e, ao acessar a rua dos fatos, visualizaram um rapaz entregando dinheiro a Lucas e Lucas entregando algo. A pessoa saiu. Lucas não atendeu à voz de parada virou de costas e foi na quina da entrada do bar, na porta. Ali ele foi abordado. Na abordagem, ele tinha R\$10,00. Na porta do bar havia mesas encostadas, na entrada

do bar, mas do lado de dentro. Havia, no meio das mesas encaixadas/empilhadas, as drogas encontradas. A outra pessoa foi embora, não conseguiram abordar. Esse outro rapaz avistou a viatura e correu. As drogas encontradas eram crack, 23 pedras. Lucas disse que as pedras não eram dele. Dentro do bar, encostados no balcão, longe da porta, havia outras 2 ou 3 pessoas. Havia outras pessoas do lado externo na outra porta. As portas ficam uma ao lado da outra, virada para a Rua Rio das Pedras. A porta em que Lucas foi abordado é a que fica mais próxima da esquina com a Rua Pedro de Vasconcelos. O local é conhecido como ponto de venda de drogas. O local é conhecido como ponto de venda de drogas. Lucas estava na rua, na lateral do bar, na Rua Rio das Pedras. As portas ficam na Rua P. de Vasconcelos. Viram ele saindo do bar antes da abordagem? Não. Pelo que avistaram, estava ocorrendo compra e venda de drogas. Viram ele mexendo nas mesas? Não. Depois da chamada de abordagem, ele mexeu a mão direita, mas não sabe se mexeu nas mesas. As drogas, na mesa, estavam todas embaladas juntas. Confirmou que avistaram a pessoa que fugiu com dinheiro em mãos e ela puxou esse dinheiro quando avistou a GCM. Não viram o que Lucas tinha em mãos. As drogas embaladas que estavam na mesa estavam em uma única sacola, não havia porções separadas.

b) Em seguida, ouvida a guarda civil Leticia Delólio Battagin. Sobre a abordagem, contou que viu Lucas e um rapaz trocando algo. O rapaz com o dinheiro puxou a nota e saiu. Lucas ignorou a abordagem e foi em direção ao bar, na esquina. Ficou parado em frente à porta, como se quisesse disfarçar. Na revista pessoal, nada localizaram. No local onde ele ficou parado, na porta do bar, havia duas mesas empilhadas. Em uma fresta, havia uma sacolinha com diversas porções que aparentava ser crack. Com Lucas não encontraram drogas, somente R\$10,00. Sobre a troca, conseguiu visualizar que era dinheiro na mão. Lucas ia entregar algo para um rapaz que estava segurando dinheiro. Quando ele visualizou a viatura, ele puxou o dinheiro e se evadiu. Chegaram bem na hora de entregar o dinheiro. Esse outro rapaz correu. Lucas ficou e não parou quando deram voz de parada. Ele não chegou a entrar no bar, ficou na porta, onde estavam as mesas. Havia outras pessoas no bar e fora, mas não próximo à mesa. O outro rapaz puxou o dinheiro do Lucas e saiu, mas não viu ele entregando o dinheiro a Lucas. O local é conhecido como ponto de venda de drogas. Lucas negou a propriedade da droga encontrada entre as mesas. Viu um movimento de mão de Lucas entregando algo, mas não visualizou o que era. Quem fazia o movimento de entregar era Lucas. O outro rapaz puxou o dinheiro, mas não viu esse rapaz entregando o dinheiro.

c) Por fim, foi interrogado o réu Lucas Fernando da Silva. É pessoa em situação de rua. Trabalha como cuidador de carros na frente do mercado Beira-Rio. Ganha por volta de R\$30,00 ou R\$40,00/dia. Tinha acabado de conseguir R\$10,00 olhando carros e foi ao local dos fatos para comprar crack. A polícia o abordou, não deu tempo de comprar a droga. Essa outra pessoa que correu também estava esperando para comprar droga. Um menino ia trazer a droga para eles fora do bar. Não atendeu de imediato o chamado da GCM porque teve receio de pegarem o seu dinheiro. Ele pediu a pedra para o traficante, ele foi para o bar buscar e a polícia chegou. Ele ficou fora do bar esperando. Esse traficante não vende dentro do bar, vende fora. Esse traficante entrou no bar para buscar a droga, a polícia chegou e ele foi preso. Não indicou o traficante para a polícia quando foi abordado porque teria encrenca (bater, matar) com o traficante depois que fosse libertado. É usuário de álcool e crack. Consegue ficar sem a droga por pouco tempo.

- DA ILICITUDE PROBATÓRIA: INCONSTITUCIONAL E ILEGAL ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL Inicialmente, deve ser reconhecida a ilicitude probatória, tendo em vista a atuação inconstitucional e ilegal da Guarda Municipal. Não bastasse, a atuação da GCM em atividade de policiamento ostensivo e investigativo, por si só, também é ilícita. Dessa maneira, a busca pessoal que resultou na apreensão das drogas foi oriunda de atuação da Guarda Civil Municipal.

Ocorre que, nos termos da Constituição Federal, art. 144, § 8º, a Guarda Municipal não tem competência para tanto. É no mesmo sentido a lição doutrinária (GASPARINI, Diógenes; As guardas municipais na constituição federal de 1988, Revista dos Tribunais. set./1991. v.671 p. 46-53; SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição, 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 638-9).

Por conseguinte, é inafastável a conclusão de que a apreensão dos entorpecentes, por guardas municipais, é medida ilícita, tornando imprestáveis, portanto, os elementos de prova daí decorrentes.

Em reforço, não há que se alegar que os guardas municipais teriam atuado legitimamente porquanto, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, seria facultado a qualquer do povo efetuar a prisão em flagrante. In casu, não há que se falar em flagrante porquanto não houve qualquer motivação legítima para proceder à abordagem, eis que, conforme relatado pelas guardas municipais, logo após a visualização do imputado, elas efetuaram a abordagem imediatamente por considerarem que ele ao visualizar a viatura o réu passou a “disfarçar”; o averiguado, portanto, não estava em situação de flagrância.

E, ainda que superado esse argumento, considerando-se legítima a prisão em flagrante, é certo que os guardas municipais carecem de competência para efetuar a busca pessoal ou buscas no local, atividades típicas de policiamento, vez que esta não é um desdobramento automático e necessário do flagrante. Tanto que a prisão em flagrante e a busca e apreensão são disciplinadas em seções autônomas do Código de Processo Penal, sendo que a busca pessoal somente será realizada quando houver “fundada suspeita” (CPP, art. 240, § 1º); enquanto a busca pessoal é uma medida de obtenção de prova, a prisão em flagrante é um ato pré-cautelar.

Ademais, o art. 241 c. c/ art. 244, ambos do Código de Processo Penal, estabelecem que a busca pessoal será conduzida pela autoridade policial. Assim, ainda que as guardas municipais, em razão do disposto no art. 144 da Constituição Federal, integrem a segurança pública, é certo que não podem ser considerados “autoridades policiais”; não por outra razão, quando efetuam a prisão em flagrante, fazem-no como “qualquer do povo”, com fundamento na parte inicial do art. 301 do Código de Processo Penal. Logo, para fins do art. 241 c. c/ art. 244, ambos do Código de Processo Penal, os guardas municipais não se equiparam às autoridades policiais. Assim, deparando-se com uma hipótese de flagrante, os guardas municipais devem apenas efetuar a custódia do indivíduo, encaminhando-o às autoridades policiais, sendo-lhes defeso efetuar a revista pessoal do cidadão detido.

Para melhor ilustrar, cite-se o habeas corpus n. 470.937-SP, em que o Superior Tribunal de Justiça considerou ilícita a revista pessoal efetuada por agente de segurança privada. Extraí-se do referido julgado, aplicável ao presente caso por analogia, que, tal como os seguranças privados, os guardas municipais poderiam ter efetuado a custódia do indivíduo, atuando como “qualquer do povo” (CPP, art. 301), mas não a sua revista pessoal (HC 470.937-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 04/06/2019, DJe 17/06/2019).

Em síntese, atuando como “qualquer do povo”, os guardas municipais podem, única e exclusivamente, efetuar a custódia de algum cidadão que esteja em situação de flagrante (CPP, art. 301), mas não podem efetuar a busca pessoal ou desenvolver atividades tendentes à obtenção de elementos de informação, sob pena de afronta ao disposto no art. 241 c. c/ art. 244, ambos do Código de Processo Penal, eis que, para esses fins, a despeito de estarem encarregados da segurança pública (CF, art. 144), não são considerados “autoridades policiais”. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (STJ, Habeas corpus 545.162/SP, Rel. Nefi Cordeiro, julgado em 4/2/2020).

Assim, tem-se que a apreensão das drogas, no caso sub examine, é elemento de prova ilícito, tendo em vista a inconstitucional atuação da Guarda Municipal. Por esse motivo, o auto de apreensão das drogas deverá ser desentranhado dos autos, eis que é inadmissível o seu ingresso no processo (CF, art. 5º, LVI c. c/ CPP, art. 157).

E, por via de consequência, o laudo de constatação e o laudo de exame químico-toxicológico são provas ilícitas por derivação, não podendo servir para formação da convicção judicial, vale dizer, mostram-se incapazes para atestar a materialidade do delito imputado ao denunciado.

Desse modo, a absolvição, nos termos do art. 386, V, do CPP, é medida que se impõe.

- DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

Caso se entenda pela licitude da atuação da guarda, de rigor a improcedência da pretensão acusatória. Isso porque, em audiência de instrução e julgamento, não foram produzidos elementos de prova que permitam concluir, além de qualquer dúvida

razoável, pela responsabilidade penal do réu (CPP, art. 386, V e VII c. c/ art. 155).

No caso concreto, não há dúvidas de que o local dos fatos é local de compra e venda de entorpecentes. O réu, aliás, confessou que tinha ido até o local para comprar crack.

As guardas contaram que viram Lucas e um outro rapaz e que esse rapaz puxou o dinheiro e fugiu. Em nenhum momento, Lucas foi visto mexendo nas drogas apreendidas. As guardas também não o viram com drogas em mãos. Em busca pessoal, somente localizou-se R\$10,00. Lucas não tinha drogas consigo, e o encontro de drogas em local que é conhecido pela traficância não pode ser imputado ao réu. Havia outras pessoas ali, e qualquer delas, inclusive a pessoa que correu, poderia ser o/a traficante.

Observa-se que, no caso concreto, eventual sentença de condenação estaria embasada apenas nas deduções das guardas municipais, elementos de prova de reduzido valor, tendo em vista a parcialidade de suas declarações. Nesse contexto, a jurisprudência do TJ-SP e a doutrina são pacíficos em lhes reconhecer o valor probatório, desde que confirmados por outros elementos de prova. Isso porque as declarações dos agentes de segurança são tendentes a confirmar a sua própria atuação, motivo pelo qual se impõe cautela na sua apreciação (TJ-SP, 7ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0373088-52.2010.8.26.0000, Relator Sydnei de Oliveira Jr; TJSP - 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin - j. 03/02/11). Assim, seria necessário que fossem confirmadas por outros elementos de prova. E tal exigência não significa um demérito à atuação dos policiais; pelo contrário, reconhece-se a importante função que desempenham, mas se pugna que suas palavras sejam apreciadas com cautela, tendo em vista as suas condições e o histórico de violência institucional que caracteriza a polícia brasileira, como, aliás, reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Cosme Rosa Genoveva vs. Brasil.

Isso posto, conclui-se que os elementos de prova disponíveis nestes autos não são suficientes para superar o standard probatório da presunção de inocência, porquanto não permitem uma conclusão, além de qualquer dúvida razoável, sobre a responsabilidade penal do acusado. De rigor, por isso, que se decrete sua absolvição, na forma do art. 386, VII, do CPP.

- DA DESCLASSIFICAÇÃO: INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS

No mais, ainda que se entenda pela suficiência probatória, impõe-se reconhecer que os elementos de prova produzidos em juízo não são suficientes para a constatação do delito de tráfico de drogas, mas, sim, para a configuração do uso de entorpecentes (LD, art. 28).

Nessa linha de raciocínio, em recente decisão, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos Autos da Revisão Criminal n. 0025831-60.2017.8.26.0000, valendo-se de pesquisas científicas efetuadas para diferenciar o traficante do usuário, rescindiu condenação proferida pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas, entendendo que os fatos estariam melhor enquadrados no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Nas palavras da Eminente Relatora, "No tocante à quantidade, creio ser importante verificar pesquisas científicas sobre o tema e o 'Estudo Técnico para Sistematização de dados sobre informações do requisito objetivo da lei 11.343/2006', de autoria de Maria Tereza Uille Gomes, de 2014, disponível em www.politicassobredrogas.pr.gov.br, traz valiosas informações de pesquisas científicas realizadas no Brasil. Vejamos: 'Estudo realizado através de pacientes da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, constatou que os pacientes viciados em cocaína utilizavam diariamente esta espécie de droga, na forma de sal, em variação de 1 a 10 (um a dez) gramas/dia, com média de 3,8 gramas por dia (ACN Nassif Filho, SG Bettega, S Lunedo, JE Maestri, F Gortz- Repercussões otorrinolaringológicas do abuso de cocaína e/ou crack em dependentes de drogas. Revista das Associação Médica Brasileira, 1999; 45(3): 237-41). Segundo o IC/PR, a médica de uso de cocaína, na forma de crack, é de 15 pedras diárias e de acordo com a Pesquisa Nacional sobre o Uso de Crack realizada por meio da parceria entre SENAD/MJ e a Fundação Oswaldo Cruz-FIOCRUZ é de 11 até 16 pedras diárias. A referida pesquisa destaca, no

entanto, que não há como definir de forma minimamente precisa o peso em gramas e o conteúdo do que cada usuário denomina 'pedra'. Desse modo, há uma subjetividade intrínseca às definições utilizadas pelos próprios usuários. Inobstante a ressalva feita pela pesquisa, a informação técnica nº 023/2-13 SETEC/SR/DPF/RS

(Superintendência Regional da Polícia Federal do Estado do RGS), constata que cada pedra de crack pode variar de 0,1 a 1,5 gramas. Segundo o estudo realizado na Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, a quantidade consumida por usuários de crack variava entre 1 a 15 gramas diárias, sendo que a média identificada foi de uso de 5,2 gramas por dia'. Ainda, no trabalho "Usuário de drogas ilícitas internados em hospitais psiquiátricos: padrões de uso e aspectos demográficos e epidemiológicos", de Paulo Borini e outros, publicado pelo Jornal Brasileiro de Psiquiatria, órgão oficial do IPUB Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do RJ, volume 52, mai/jun 2003, estudo realizado em um hospital psiquiátrico, informa que cerca de 51% são usuários de monodroga e 49% de polidroga. Indica que o consumo diário era igual ou menor de 15 (quinze) gramas de crack, 10 (dez) gramas de maconha e 5 (cinco) gramas de cocaína." (p. 8-9 do Acórdão)".

Outrossim, é necessário atentar-se ao fato de que a discricionariedade policial, consistente no poder de apontar se o indivíduo abordado é usuário ou traficante, deve ser contida em âmbito judicial. Como explica, a propósito, Luís Carlos Valois: "A possibilidade de aquele policial militar decidir, na esquina, se a pessoa abordada é usuária ou traficante de drogas é a mais grave das discricionariedades dessa guerra [guerra às drogas]. Do veredito das ruas poucos podem se livrar e, sacramentado o julgamento, seguirá o indiciado tendo que provar sua inocência com a grande dificuldade de um processo onde todas as testemunhas são policiais" (VALOIS, Luís Carlos. O direito penal da guerra às drogas. 3. ed. Belo Horizonte: D'Plácido, 2019, p. 28).

Por isso, para conter eventuais abusos e evitar injustas condenações, é necessário demonstrar, de maneira inequívoca, que as drogas apreendidas em poder dos acusados se destinavam à comercialização, o que não ocorreu no presente caso. Assim, impõe-se a desclassificação, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça:

"PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. Apelo do Ministério Público pela condenação por tráfico, nos termos da denúncia. Inadmissibilidade. Não demonstrado o intuito de entrega do entorpecente a consumo de terceiros. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Desclassificação mantida. Apelo ministerial desprovido. Julgada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o apelo defensivo" (TJ-SP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0001018-

89.2017.8.26.0542, Rel. Diniz Fernando, julgado em 16/3/2020).

Com isso, resta configurada a conduta de uso de drogas, e mostra-se imperiosa a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas. E, uma vez efetuada a desclassificação, exsurtem algumas consequências.

a) Absolvição por inconstitucionalidade do tipo

A primeira delas é a necessária absolvição em razão da inconstitucionalidade do referido tipo previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, o qual fere o disposto no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. Isso porque é inquestionável que a criminalização da posse de drogas para consumo pessoal afeta de modo desproporcional o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e à autodeterminação, em suas diversas manifestações.

Nas palavras de Salo de Carvalho: "Os direitos à intimidade e à vida privada instrumentalizam em nossa Constituição o postulado da secularização que garante a radical separação entre direito e moral. Neste aspecto, nenhuma norma penal criminalizadora será legítima se intervier nas opções pessoais ou se impuser padrões de comportamento que reforcem concepções morais. A secularização do direito e do processo penal, fruto da recepção constitucional dos valores do pluralismo, da tolerância e do respeito à diversidade, blinda o indivíduo de intervenções indevidas na esfera da interioridade. Assim, está garantida ao sujeito a possibilidade de plena resolução sobre os seus atos (autonomia) [...]" (CARVALHO, Salo de. A política criminal de drogas no Brasil: estudo criminológico e dogmático da Lei 11.343/06. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 343-344). Adicionalmente, o art. 28 da Lei de Drogas ofende o princípio da lesividade. Ora,

um dos preceitos básicos do Direito Penal é a alteridade da lesão, vale dizer, somente se pode criminalizar conduta que ofenda bem jurídico alheio. Como escreve, a propósito, Nilo Batista: "O mesmo fundamento veda a punibilidade da autolesão, ou seja, a conduta externa que, embora vulnerando formalmente um bem jurídico, não ultrapassa o âmbito do próprio autor, como por exemplo o suicídio, a automutilação e o uso de drogas. No Brasil, o art. 28 da Lei n. 11.343, de 23.ago.2006, que incrimina o uso de drogas, em franca oposição ao princípio da lesividade e às mais atuais recomendações político-criminais" (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 12. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 90).

Se é assim, tem-se que o consumo de drogas não ofende qualquer bem jurídico alheio, centrando-se na livre determinação do indivíduo que opta por fazer uso do entorpecente.

Desse modo, é inquestionável que qualquer lesão potencial e suposta à saúde pública não pode ser utilizada para legitimar a intervenção penal no indivíduo. A título exemplificativo, o tabaco e o álcool ofereceriam lesividade, mas sua venda e consumo não são criminalizados. Para tais casos, é incontestável que o incremento de medidas restritivas de caráter administrativo, assim como políticas públicas de conscientização sobre o uso abusivo de tais substâncias se mostram eficazes. O mesmo raciocínio deve ser aplicado em relação às demais drogas.

Anote-se, em reforço, que a criminalização do usuário tem o efeito perverso de rotulá-lo como marginalizado, o que dificulta a sua recuperação, especialmente em se tratando de jovens, que são o principal grupo consumidor de substâncias ilícitas.

Diante da alegação ora invocada, de rigor seja declarada a inconstitucionalidade do tipo penal, em sede de controle difuso, com consequente afastamento da imputação da conduta tipificada pelo art. 28 da Lei de Drogas e absolvição, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

b) Aplicação de sanção na forma do art. 28 da Lei de Drogas

Rejeitada a pretensão de inconstitucionalidade, mas operada a desclassificação, é o caso de aplicação das sanções cominadas pelo art. 28 da Lei de Drogas.

- DAS ALEGAÇÕES RELATIVAS À DOSIMETRIA DA PENA

a) Pena-base

Na remota hipótese de condenação, de rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal: as consequências e a culpabilidade são normais para o caso, não justificando uma reprovação penal maior. No mais, os antecedentes do réu devem ser considerados na segunda fase dosimétrica.

b) Da segunda fase da dosimetria

Na segunda fase, há a reincidência do réu, permitindo o aumento da pena em 1/6. Ausentes outras considerações a serem feitas acerca da pena.

- DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, não aplicável ao caso o regime fechado. Em atenção ao disposto no art. 33, § 3º, diante da quantidade pena a ser aplicada e das circunstâncias judiciais, inexistindo fundamentação concreta a recomendar o regime mais gravoso (Súmulas 718 e 719 do STF; Súmula 440 do STJ), de rigor a aplicação do regime diverso do fechado.

Adicionalmente, para a fixação do regime inicial, não poderá ser observado o disposto no art. 1º, § 2º, da LCH, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade pelo STF, exercendo sua função típica de guardião da Constituição e, por isso, proferindo uma decisão de observância obrigatória por todo o Judiciário (CF, art. 102 c. c/ art. 927 do CPC).

- DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

Finalmente, deve ser assegurado ao acusado o direito de apelar em liberdade. De acordo com o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, ao proferir uma sentença de condenação, "O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". Ademais, a decisão pela manutenção da prisão preventiva deve ser concreta, cabendo ao julgador "[...] indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem

a aplicação da medida adotada" (CPP, art. 315, § 2º). Com efeito, uma vez encerrada a instrução, ainda que se entenda pela manutenção da prisão preventiva anteriormente exposta, a decisão deve ser concretamente fundamentada, visto que ainda vigente o estado de inocência (CF, art. 5º, LVII; CADH, art. 8.2).

No mais, no atual cenário, qualquer decisão que determina o recolhimento de alguém ao cárcere ou a manutenção de uma prisão anteriormente decretada deve ser ponderada à luz da crise sanitária causada pelo COVID-19. Considerando a situação emergencial de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19), somada ao fato de que estabelecimentos em que há aglomeração de pessoas privadas de liberdade são muito mais suscetíveis à disseminação de doenças virais, e visando a reduzir ao máximo os riscos advindos de uma possível contaminação por coronavírus, principalmente dos sujeitos ainda protegidos pela presunção de inocência e acusados de crime não considerados graves, mostra-se imperiosa a concessão do direito de apelar em liberdade, caso o acusado seja condenado.

Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

LUCAS FERNANDO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 05 de outubro de 2021, por volta de 20h17, no "Bar da Pantera", localizado à Rua Pedro Ferraz Pacheco, bairro Piracicamirim, nesta cidade e comarca, mantinha em depósito e/ou guardava 23 porções de cocaína, destinadas à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, substância entorpecente que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, guardas civis passavam pelo local, quando avistaram o réu em atitude típica de tráfico ilícito de drogas, ou seja, "um indivíduo entregando algo para outro que lhe entregou um objeto que parecia ser uma nota de real". Ao perceber a aproximação da viatura, a pessoa que entregava o dinheiro puxou a nota da mão do réu e correu. Em seguida, o réu passou a disfarçar ao lado de uma mesa do estabelecimento.

Feita abordagem de praxe, em poder do réu foi localizada a quantia de R\$ 10,00 e, em uma fresta na mesa ocupada por ele, foram encontradas 23 porções de cocaína. Instado, informalmente, o réu negou a propriedade da droga. Perante a autoridade policial, ele permaneceu em silêncio.

Diante das circunstâncias apuradas, local, apreensão de porções individualizadas e apreensão de dinheiro, infere-se que a droga apreendida destinava-se à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas.

A denúncia foi oferecida, sem oferecimento de acordo de não persecução penal (fls. 100/101) sendo determinada a notificação do réu para oferecer defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 102/103).

Notificado (fls. 109), o réu apresentou defesa prévia, na qual pleiteou a revogação da prisão preventiva e alegou inocência (fls. 113/116).

A denúncia foi recebida, designando-se a audiência virtual (fls. 134/137). O réu foi citado (fls. 154).

Durante a instrução, foram ouvidas 02 testemunhas comuns, sendo o réu interrogado. Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestam.

É o relatório.

DECIDO.

I - Da Preliminar

Pleiteia a Defesa, o reconhecimento da nulidade do processo, em razão da prisão realizada por guardas municipais. Argumenta que houve diligência típica de atividade policial, não permitida aos guardas municipais.

Não há, contudo, qualquer nulidade na prisão em flagrante do réu.

Não se verifica qualquer abuso ou ilegalidade na diligência efetuada pelos guardas municipais que apenas abordaram o réu, em ponto de venda de drogas, após visualizarem conduta típica de troca de objeto por dinheiro.

Por fim, a Lei nº 13.022/14 conferiu expressamente à Guarda Municipal a atribuição de polícia ostensiva, nos termos do artigo 3º da referida legislação, que assim

dispõe: "Artigo 3º. São princípios mínimos de atuação das guardas municipais: I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas; II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas; III - patrulhamento preventivo; IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e V - uso progressivo da força".

De qualquer modo, nada obstante o disposto no artigo 144, parágrafo 8º, da Constituição Federal, é certo que, à luz do artigo 301 do Código de Processo Penal, não há uma proibição de que os guardas municipais prendam alguém em flagrante, haja vista que qualquer pessoa do povo também pode fazê-lo.

E, no caso concreto, ao contrário do postulado pela Defesa, o réu foi abordado na guarda da droga, logo após os guardas civis terem avistado a troca de objeto por dinheiro, havendo flagrante, consoante prevê o artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal - CPP.[...] 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.º 603.686/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 9/2/2021, DJe 17/2/2021) Ante o exposto, não conheço o presente habeas corpus. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2021. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Relator. (STJ - HC: 676532 SP 2021/0199414-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 29/06/2021).

"O recurso comporta parcial provimento. No caso, quanto à prisão em flagrante realizada por guardas municipais, inexistente ofensa aos alegados dispositivos de lei federal, pois o entendimento do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência desta Corte consolidada no sentido de que, "apesar das atribuições previstas no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, se qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância, não se pode proibir o guarda municipal de efetuar tal prisão" (HC n. 286.546/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 15/10/2015). Nesse sentido, confira-se ainda: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. "É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal" (HC 471.229/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 1º/3/2019) 5. Habeas Corpus não conhecido. (HC 525.772/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019). Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para, na segunda fase da dosimetria, compensar integralmente a agravante de reincidência com a atenuante de confissão, fixando a pena definitiva do paciente em 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 11 dias-multa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2021. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Relator (STJ - REsp: 1940142 SP 2021/0159530-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 28/06/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO FLAGRANCIAL ILEGAL. GUARDA MUNICIPAL PODE PROMOVER PRISÃO EM FLAGRANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A primeira parte do art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Desse modo, inexistente ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais. 2. Conforme compreensão da Sexta Turma desta Corte Superior, havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia

investigativa. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 667413 SP 2021/0152075-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2021)

Nesse sentido também o Tribunal de Justiça de São Paulo:

PRELIMINAR. ILICITUDE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. FALTA DE COMPETÊNCIA PARA O ATO. INEXISTÊNCIA. O Estatuto das Guardas Municipais (Lei nº 13.022/14), regulamentou o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, estabelecendo que compete à Guarda Civil Metropolitana, entre outras atribuições, prevenir, inibir e coibir infrações penais, bem como encaminhar indivíduos em flagrante delito à autoridade policial (art. 5º, II, III e IV da referida Lei). Ademais, como qualquer do povo, esses servidores podem efetuar a prisão em flagrante do agente cuja conduta se amolde às hipóteses taxativas do artigo 302 do Código de Processo Penal. Guardas civis municipais que foram alertados por transeunte sobre a conduta do réu, dirigiram-se ao local, observaram a prática de atos típicos de traficância e efetuarão sua prisão em flagrante delito. Ausência de ilicitude da busca pessoal que culminou na apreensão das drogas e dinheiro e o início da persecução penal. Preliminar rejeitada. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Guardas civis, após denúncia de traficância, avistaram o réu Yan em movimentação típica de tráfico com dois indivíduos e o surpreenderam na posse de duas porções de cocaína, vindo a localizar, no local de onde empreendera fuga, outras cinco porções da mesma droga, idênticas, e R\$ 20,00. Silente na fase extrajudicial, apelante negou em juízo o tráfico de drogas. Negativa e versão judiciais, além de fantasiosas e inverossímeis, sucumbiram à prova produzida pela Acusação. Condenação mantida. PENAS. Base fixada no mínimo legal. Pleito ministerial atendido para reconhecer-se a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, haja vista a prática do crime durante o estado de calamidade pública da pandemia de COVID-19, mormente no caso dos autos, em que se apura crime que visa a resguardar a saúde pública. Mantido o reconhecimento da reincidência. Negada a aplicação do redutor, por vedação legal expressa. Pena majorada. REGIME PRISIONAL. Regime inicial fechado mantido, ante a quantidade de pena aplicada e a reincidência específica, além da gravidade concreta do delito praticado. Regime inicial fechado mantido. BENEFÍCIOS LEGAIS. Incabíveis o sursis penal e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, ante a quantidade de pena corporal (superior a quatro anos) e a reincidência específica do réu. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelo defensivo desprovido, com provimento ao recurso ministerial para, reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal, redimensionar suas penas para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa mínimos, com expedição de ofício de recomendação em seu desfavor. (TJ-SP - APR: 15015986320208260599 SP 1501598-63.2020.8.26.0599, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 29/06/2021, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/06/2021 - grifei).

"Pondera-se, também, que em casos como o dos autos, por ser o tráfico de drogas um delito permanente, possível é a prisão flagrancial, a qualquer tempo e por qualquer um do povo, a teor do que dispõe o art. 301 do Código de Processo Penal. Destarte, não há impedimento legal para que membro da Guarda Civil Metropolitana efetue prisões em flagrante. Nesse sentido é a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE EFETUADO POR GUARDA MUNICIPAL. VALIDADE. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INAPLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte Superior, é possível que, diante de notitia criminis, envolvendo qualquer dos bens jurídicos mencionados, o agente municipal proceda à atividade de vigilância no local indicado para se certificar de sua veracidade, hipóteses nas quais, de nenhum modo, estaria desautorizado a agir. 2. A situação de flagrância delitiva legitima a atuação de "qualquer pessoa do povo" a proceder à prisão, oportunidade em que é perfeitamente possível a realização da abordagem do suspeito, não sendo diferente em relação àqueles agentes que, ao realizarem seu mister de zelar pelo patrimônio público, muitas vezes se deparam com infrações penais, sendo-

lhes lícito atuar em tais ocasiões. Precedentes. [...] 8. Ordem denegada. (HC 583.610/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 14/08/2020). PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. CONDUTA FLAGRADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. [...] III - O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva